

1511216-44.2021.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Cynthia Torres Cristofaro
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 23ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/02/2022

... da punição.

Nesse sentido:

Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Apreensão de maconha -
Insurgência do réu - Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei nº
11.343/2006 - Não cabimento - Circunstâncias da prisão e quantidade de
entorpecentes apreendidos que afastam tal pretensão - Dicção do disposto no art.
33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Dosimetria. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
23ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1511216-44.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1511216-44.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autora:

Justiça Pública

Réu:

MIGUEL ANGEL GAMARRA, JOSE VENANCIO TELES FERREIRA e CLEITON CABRAL

Juíza de Direito: Dra. Cynthia Torres Cristófar

Vistos.

MIGUEL ANGEL GAMARRA, JOSE VENANCIO TELES FERREIRA e CLEITON CABRAL, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos I e IV, em combinação com o artigo 61, inciso II, alínea j, ambos do Código Penal, porque teriam, no dia 5 de maio de 2021, por volta de 1h15min, na Rua Anhaia nº 953, Bom Retiro, nesta cidade e Comarca, durante a vigência do estado de calamidade pública decretado em decorrência da pandemia do covid-19, previamente ajustados e em identidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, subtraído para si aproximadamente 10 (dez) quilos de alumínio, avaliados em R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), pertencentes a Lucas F. E. J. K..

Os réus foram presos em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 75/78), deferida liberdade provisória no curso do feito (fls. 199/200).

Recebida a denúncia (fls. 136/137), os réus foram regularmente citados (fls. 160, 171 e 183) e apresentaram resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (fls. 186/187), ratificado o recebimento da denúncia (fls. 189).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima e os depoimentos de duas testemunhas, tendo sido os réus interrogados.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação dos acusados, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas, requerendo subsidiariamente que fossem afastadas agravante e qualificadoras, não caracterizadas ou comprovadas, sendo penas fixadas no mínimo, atenuadas por confissão, em regime brando tomada detração, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, sendo facultado recurso em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória merece parcial acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, sendo clara a tipicidade da conduta, não havendo dúvidas quanto à autoria no que toca a Cleiton e Miguel, mas não suficientemente comprovada a participação de José Venancio.

O réu Cleiton, ouvido na fase policial negou a prática delitiva, sem maiores esclarecimentos (fls. 12); ouvido em Juízo, admitiu a prática do delito, junto com o corréu Miguel; os materiais de alumínio estavam fora do estabelecimento, então pegaram-nos; não arrombaram a porta do imóvel, já estava arrombado havia algum tempo, vinha sendo utilizado por usuários de crack; era também usuário de crack, sendo que outros usuários comentaram que o local estava abandonado; os materiais já estavam soltos, na calçada, no chão; o réu José Venâncio vinha passando com uma carroça, não o conheciam até então, chamaram-no e pediram que os ajudasse a levar o material para um ferro velho, não informaram para ele onde tinham apanhado o material, iam pagar a ele 50 reais; não conhecia a vítima ou os policiais; negou condenações anteriores.

O réu José Venâncio, ouvido na fase policial, afirmou que foi pegar um material de reciclagem com os demais acusados, sem saber de onde estes o retiraram (fls. 13); ouvido em Juízo, negou a prática do furto; trabalha com uma carroça de reciclagem, estava indo ao ferro-velho; encontrou os corréus, que até então não conhecia, que lhe ofereceram um dinheiro para que levasse um material para a reciclagem; o material já estava com eles, disseram que tinham retirado de uma caçamba; colocou o material na carroça e foi levando, eles foram atrás; eles iriam lhe pagar 50 reais depois que o material fosse vendido, acredita que valeria uns 200 reais; estavam distantes do ferro velho, que era próximo da Estação da Luz; foram abordados pela polícia, não teve oportunidade de dar suas explicações aos policiais; não conhecia a vítima ou os policiais anteriormente; negou condenações anteriores.

O réu Miguel, ouvido na fase policial, negou o delito, dizendo que encontraram os materiais em uma caçamba (fls. 15); ouvido em Juízo, negou a prática do delito; os materiais estavam na frente do prédio, já soltos, quebrados; estava junto com Cleiton, então recolheram esse material; vinha passando o réu José Venâncio, que até então não conhecia, com um carrinho, então pediram para ele levar o material, iam pagar 50 reais a ele, não comentaram onde tinham apanhado o material; não arrombaram o local, estava já fazia algum tempo aberto, sendo que usuários de crack estavam indo ali retirar materiais, na ocasião havia bastante gente dentro do imóvel, porém não chegaram a entrar; quando foram abordados pelos policiais, o material estava dentro do carrinho, não tiveram muito como explicar a situação aos policiais; não conhecia a vítima ou os policiais anteriormente; tem condenação anterior por furto, estava em RA.

As negativas apresentadas pelos acusados Cleiton e Miguel, carentes de verossimilhança, vêm isoladas nos autos, confrontadas pelo mais da prova colhida, a qual demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória ao menos no tocante a eles. Já a negativa dada por José Venâncio encontra respaldo nas alegações dos corréus, que o eximiram de participação, não bastando o mais da prova a convencer com a necessária segurança de que tenha colaborado para a subtração.

As circunstâncias da prisão dos réus e da apreensão da res foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então os acusados, apresentaram relatos detalhados e convincentes, coincidentes entre si

e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido. O policial militar Robson relatou em Juízo que recebeu informação do Copom de que indivíduos estavam arrombando uma loja, dado o endereço; foram ao local e na mesma rua, a dois quarteirões da loja, deram com os três réus, que iam caminhando juntos, sendo que o réu Cleiton (apontado) carregava um saco cheio de peças de alumínio; esse réu confessou que havia furtado as peças da loja, a testemunha não se recordava se informou se o havia feito sozinho ou com os demais, tampouco se lembrava se os demais réus lhe deram alguma declaração no local; foram à loja, a tranca da porta estava arrombada e na parte superior estavam faltando as peças de alumínio das portas e janelas.

A policial militar Franciele descreveu em Juízo que estavam próximos do local quando foram informados pelo Copom de um furto em andamento; foram ao local e, na mesma rua, a cerca de dois quarteirões, localizaram os três réus, que caminhavam juntos; o réu Cleiton (apontado) estava carregando uma sacola com peças de alumínio brancas, de portas e janelas; esse réu confessou o furto, os demais não lhe deram nenhuma declaração no local; no local viram que a porta do imóvel estava arrombada, dentro havia uma escada que dava acesso à parte de cima, onde faltavam as peças das portas e janelas; não teve contato com a vítima na ocasião; os réus foram abordados e conduzidos na mesma noite em que ocorreu o furto.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a eles prestada por ocasião da abordagem pelo réu Cleiton, convindo notar que os réus não eram conhecidos anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

A vítima, a seu turno, explicou que é proprietário do imóvel em questão, que estava para alugar, vendo-se que tomou conhecimento do furto por meio da imobiliária que tinha placa afixada no imóvel passados alguns dias do furto (os réus foram presos em flagrante em 5 de maio de 2021 e a vítima foi ouvida na delegacia, referindo ter tomado conhecimento do furto no dia anterior, em 13 de maio de 2021 (fls. 93), sendo certo que identificou os objetos subtraídos e os recuperou na delegacia, bem assim que deu conta do arrombamento da porta do imóvel.

Não há nos autos indicação de qualquer motivo para que vítima e testemunhas mentissem, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar os réus, que nem conheciam, assomando evidente que compareceram tanto perante a autoridade policial como em Juízo imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade. Bem esclarecido, assim, que os três acusados foram surpreendidos juntos a pouca distância ainda do local do furto levando consigo os objetos furtados, os quais foram retirados das instalações.

Consoante se observa do laudo pericial do local (fls. 219/225), não se trata em absoluto de imóvel abandonado. Trata-se de uma loja momentaneamente desocupada e posta para alugar, com anúncio de imobiliária colocado na fachada inclusive, que nada indica viesse sendo diuturnamente dilapidado como dito pelos réus Cleiton e Miguel.

É cediço que a apreensão da res em poder dos acusados gera forte presunção de autoria, a ser elidida pela apresentação de justificativa plausível, a qual não veio no caso em exame, em que antes admitiram Cleiton e Miguel a tomada dos bens, que procuraram convencer, sem sucesso, que estavam já retirados e acumulados na rua. Apenas José Venâncio deu justificativa razoável para a posse das peças metálicas, explicando que as transportava em seu carrinho para um ferro-velho a pedido dos corréus, que iriam pagar-lhe R\$ 50,00, encontrando essa alegação confirmação nas declarações dos demais.

O conjunto probatório, ao menos no que toca a Cleiton e Miguel, é seguro e convincente, dado que é pelos relatos coincidentes das testemunhas sem justificativa verossímil para a apreensão, bem assim pelo informado pela vítima, tudo conforme à prova técnica produzida, de tal sorte que materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente comprovadas.

Quanto ao repouso noturno, não veio demonstração nos autos de que relevante a circunstância de o furto ter se dado à noite para o desenvolvimento da subtração,

nada dizendo que estivesse vigilância habitual sobre o bem reduzida ou limitada em razão da vigência da noite, relevando notar que a res não estava abrigada em local de moradia habitado, mas sim em imóvel comercial desocupado, indiferente nessa situação estivesse vítima desperta ou dormindo.

Não fosse isso, não mereceria incidência a causa de aumento prevista pelo parágrafo 1º ao artigo 155 do Código Penal diante do furto qualificado, já que "a pena pelo furto qualificado não pode ser aumentada por ter sido praticado durante o repouso noturno. A majorante do § 1º do art. 155 do CP só é aplicável às hipóteses de furto simples" (TJSP - AC - Rel. Diwaldo Sampaio - RT 639/278) (FRANCO, Alberto Silva et alii, "Código Penal e sua interpretação jurisprudencial", 5ª edição, São Paulo, RT, 1995, p.1912).

A comparsaria restou evidente, compreendendo-se da própria conduta, caracterizada por atuação concatenada entre os agentes com repartição de atos de execução, o ajuste de vontades entre eles, caracterizada participação equivalente e igualmente importante de ambos, ademais relevante a circunstância para incrementar o potencial de êxito da empreitada, incidindo a qualificadora.

Bem comprovado o rompimento de obstáculo, constatados por perito judicial e descritos no laudo pericial de fls. 219/225 os danos produzidos em ordem a propiciar o acesso à res, consistentes no arrombamento da porta de pedestres existente ao lado da porta principal do imóvel de comércio, de sorte que caracterizada a qualificadora.

É certo que a consumação foi atingida, desde que conquistada e aproveitada, ainda que por tempo breve, posse desvigiada da res, retirada da instalação no imóvel e levada pelos agentes quando tomaram rumo sem que ninguém os perturbasse, resultando a subsequente recuperação da res de casual intervenção policial bem sucedida já inserida em desenrolar causal autônomo.

A conduta, que abrangeu arrombamento e retirada das peças de suas instalações, é típica, não tendo a res valor insignificante ou ínfimo, ademais apta a conduta a produzir lesão patrimonial, a par de encerrar em si desvalor social que reclama intervenção estatal.

A condenação de Cleiton e Miguel é de rigor. Passo à dosagem das penas que serão impostas a esses acusados.

Ao delito descrito pelo artigo 155, parágrafo 4º, do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser de todo desfavoráveis aos acusados, fixo a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Atenuantes genéricas não incidem, dado não terem o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, frente ao princípio da legalidade (Súmula STJ 231).

O réu Miguel é reincidente, como comprova a certidão de fls. 59/62 caracterizada a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal, que motiva aumento de um sexto na base, que vai a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Observe que não veio confissão, desde que o réu em seu interrogatório negou a subtração, afirmando que apenas recolheu da rua as peças já removidas de sua instalação no imóvel, o que se viu não corresponder à verdade.

Não atua, ademais, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, apontada na denúncia, reformulado, nesse ponto, o entendimento desde Juízo.

Com efeito, muito embora o crime realmente tenha sido praticado quando em vigor situação de calamidade assim reconhecida pelo poder público, decorrente da pandemia da doença provocada pelo corona vírus, não se observa que essa circunstância tenha sido algo relevante na prática do delito ou mesmo que da conduta tenha resultado algum efeito sobre a situação calamitosa.

Tratando-se, no caso, de circunstância meramente accidental, que não propiciou facilidade para a prática criminosa e nem tampouco foi impactada pela conduta do réu, não justifica o agravamento da punição.

Nesse sentido:

Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Apreensão de maconha - Insurgência do réu - Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei nº

11.343/2006 - Não cabimento - Circunstâncias da prisão e quantidade de entorpecentes apreendidos que afastam tal pretensão - Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Dosimetria. Primeira fase - Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e da quantidade de entorpecente apreendido (quase 1 kg de maconha), na fração de 1/6 (05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa). Segunda fase - Atenuante de confissão espontânea compensada com a agravante de reincidência - Ainda na segunda fase, incidiu a agravante de calamidade pública em razão do Covid19, na fração de 1/6 - Respeitado o entendimento do nobre julgador, a agravante contida no art. 61, II, alínea "j", CP, não tem aplicação no caso - Inexistência de relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública (Coronavírus) e a prática do tráfico de drogas - A exasperação da pena é devida quando o agente se aproveita de uma situação, para o cometimento do crime, o que não ocorre na espécie - Agravante afastada. Terceira fase - Redutor que não incidiu na espécie - Réu reincidente - Regime fechado que fica mantido - Recurso provido em parte para afastar a agravante de calamidade pública, redimensionando-se, assim, o quantum da reprimenda. Mantida, no mais, a r. sentença. (TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, Apelação Criminal 1516263-33.2020.8.26.0228, deram parcial provimento, V.U., j. 25/3/2021).

No mesmo sentido: TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Andrade Sampaio, Apelação Criminal 1512777-40.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021; TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Andrade Sampaio, Apelação Criminal 15'6422-

73.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021; e TJSP, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Francisco Bruno, Apelação Criminal 1517341-62.2020.8.26.0228, j. 25/3/2021.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta a Cleiton, fixo o regime aberto, adequado à consecução das finalidades da sanção penal. Preenchidos os requisitos legais (art. 44, caput, e § 2º, segunda parte, CP), substituo a pena corporal por mais uma pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa e por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período da pena substituída, à razão de uma hora por dia de condenação, consoante determinar o Juízo da execução.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta a Miguel, fixo o regime semiaberto, adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a reincidência do réu, a qual, a par de obstar a adoção de regime mais brando, impede substituição ou suspensão condicional da pena corporal, medidas que, não se afigurando socialmente recomendáveis (art. 44, § 3º, CP), não se afiguram capazes de propiciar o escopo da punição.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câm. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

À mingua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas dos acusados, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar, por infração ao artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal, o réu MIGUEL ANGEL GAMARRA, identificado a fls. 47, às penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo; e o réu CLEITON CABRAL, identificado a fls. 49, às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime

inicial aberto, substituída por 10 (dez) dias-multa e por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período de dois anos, à razão de uma hora por dia de condenação, conforme dispuser o Juízo de execução, e mais 10 (dez) dias-multa, todos no valor unitário mínimo; bem como para absolver o réu JOSE VENANCIO TELES FERREIRA, identificado a fls. 48, da imputação a ele feita, com fundamento no disposto pelo artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Ausentes causas para a prisão processual, tendo os réus respondido soltos, sem percalços, ao processo, faculto-lhes o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado a) elabore-se cálculo de multa e intimem-se os réus Cleiton e Miguel para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandado de prisão contra o réu Miguel, e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia; c) expeça-se carta de guia em relação ao réu Cleiton; d) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais na data abaixo indicada. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.

VAI ESTE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME É APONTADO EM SUA MARGEM SUPERIOR / DIREITA